

1524150-34.2021.8.26.0228
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 6ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 28/04/2022
... j. 31/05/2012).

E ainda: "PENA - Fixação - Tráfico ilícito de entorpecentes - Aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei Federal n. 11.343/06 - Inviabilidade - Agente surpreendido quando trazia consigo 59 porções de maconha e 11 de cocaína - Quantidade de drogas apreendidas indicadora de que o réu faz do tráfico seu meio de vida, ou seja, de que se dedica à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
6ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1524150-34.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1524150-34.2021.8.26.0228
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2271007/2021 - 67º D.P. JARDIM ROBRU, 20647080 - 67º D.P. JARDIM ROBRU, 832/21/355 - 67º D.P. JARDIM ROBRU, 2271007 - 67º D.P. JARDIM ROBRU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PEDRO MIGUEL PEREIRA NOGUEIRA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

PEDRO MIGUEL PEREIRA NOGUEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c. c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 04 de outubro de 2021, por volta das 16h00, na Rua Raça Negra, altura do numeral 28, Itaquera, nesta capital, nas imediações de estabelecimento de ensino ("CEI João Fernandes"), trazia consigo, para fins de tráfico, 74 invólucros contendo, aproximadamente, 1.266g de substância conhecida como "maconha" e 20 microtubos contendo, aproximadamente, 48,7g de substância

conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 137,00 em espécie.

O acusado foi notificado nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 11.343/06 e apresentou Defesa Prévia (págs. 347/359).

Recebida a denúncia (págs. 377/383), durante a instrução criminal, foram inquiridas as testemunhas arroladas, interrogando-se o acusado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça insistiu na condenação, nos exatos termos da denúncia.

O Dr. Defensor, por sua vez, requereu, preliminarmente, seja determinada a realização de exame de dependência toxicológica no acusado. Outrossim, levantou preliminares de nulidade por "violação aos direitos constitucionais", "falta do Laudo Pericial" e "violação às normas infraconstitucionais e às normas processuais penais".

No mérito, pugnou pela absolvição e sustentou, em síntese, que a prova produzida é precária. Subsidiariamente, requereu: (I) fixação da pena-base no mínimo legal; (II) aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; (III) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; (IV) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (V) devolução do telefone celular apreendido nos autos; (VI) regime inicial de cumprimento da pena diverso do fechado; e, por fim, (VII) seja assegurado ao réu o direito de interpor recurso em liberdade.

É o relatório.
D E C I D O.

Por primeiro, indefiro a pretensão formulada pela Douta Defesa para instauração do incidente de dependência toxicológica.

Com efeito, não há elementos nos autos que indiquem a necessidade de realização do referido exame, porquanto não há mínimos indícios de que o acusado seja, de fato, dependente químico.

Durante o interrogatório, o acusado apresentou-se bem orientado e consciente, sem qualquer alteração de ânimo ou perturbação mental em decorrência do uso de entorpecentes ou da alegada abstinência.

E como já se decidiu: "Réu usuário de drogas - Exame de dependência química ou de insanidade mental - Ausência de prova de comprometimento da capacidade de entendimento do fato - Desnecessidade - Nulidade inexistente. (...) O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aferir a necessidade da diligência, sem que o indeferimento acarrete cerceamento de defesa se não se vê prejuízo para o esclarecimento dos fatos. Na verdade, o exame em questão só se justifica e se impõe quando o Juiz se convence, pelas evidências existentes nos autos, de que o acusado tinha diminuída ou prejudicada a capacidade de entender o caráter ilícito do fato em decorrência do uso de entorpecentes no momento do crime. Por aqui, o que se percebe do registro audiovisual do interrogatório judicial é que nada indica que o réu tivesse se apresentado à Magistrada com alteração de ânimo, ou perturbação mental em decorrência do uso de entorpecente ou mesmo em razão da abstinência do consumo dessa substância ou até de medicamento. Ao contrário, apresentou respostas claras, objetivas e incompatíveis com a conduta daquele que tem a chamada síndrome de abstinência, tudo evidenciando sua higidez mental. Preliminar rejeitada." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1506369-18.2020.8.26.0136, Relator(a): Alexandre Almeida, 11ª Câmara de Direito Criminal, DJe em: 31/05/2021).

"APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença condenatória - Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa - Inocorrência de nulidade - Ausência de instauração de exame de dependência química toxicológica - Não comprovação dos requisitos necessários para a instauração do incidente - Defesa não experimentou qualquer prejuízo - (...) PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1500689-43.2019.8.26.0603, Relator(a): Fátima Gomes, 9ª Câmara de Direito Criminal, DJe em: 16/12/2021).

E ainda: "A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do magistrado" (STJ - HC nº 336.811/SP, Relator(a): Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe em: 01/08/2016).

"A simples alegação da condição de usuário não constitui elemento suficiente para justificar a realização da perícia toxicológica" (STJ - HC nº 402.245/SP, Relator(a): Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe em: 15/08/2017).

Bem ao contrário, a prova produzida no contraditório demonstrou que à época do crime o acusado gozava de plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Tanto é assim que, em Juízo, tanto o acusado quanto sua genitora, Regilda Pereira Nogueira - arrolada pela Defesa - afirmaram que ele estava matriculado na escola e estudava à época dos fatos. Ora, se o acusado estudava normalmente, não é mesmo crível que ele tivesse sua higidez mental comprometida pela dependência química.

Logo, diante da absoluta inexistência de elementos que indiquem a condição de dependente químico do acusado, referido incidente fica indeferido, até porque eventual condição de usuário não afasta a de traficante.

Afasto as preliminares de nulidade levantadas pela Defesa.

Por primeiro, com relação às aventadas nulidades por "violação aos direitos constitucionais" e "violação às normas infraconstitucionais e às normas processuais penais", o Dr. Defensor limitou-se a apresentar alegações vagas e genéricas, no sentido de que os depoimentos prestados pelos policiais teriam "contaminado o processo de forma irreparável, causando extremo prejuízo ao réu", sem sequer especificar vício que teria causado tal contaminação, ou apontar o prejuízo sofrido.

No mais, conforme se depreende da simples leitura do termo de interrogatório digitalizado à pág. 11, o acusado foi cientificado pela Autoridade Policial acerca de seus direitos constitucionais individualmente previstos, dentre os quais "os de receber assistência de familiares ou de advogado que indicar, de não ser identificado criminalmente senão nas hipóteses legais, de ter respeitadas suas integridades física e moral, de manter-se em silêncio e/ou declinar informações que reputar úteis à sua autodefesa, de conhecer a identidade do autor de sua prisão".

Não é despidendo frisar que os documentos emitidos pela Autoridade Policial no âmbito do inquérito policial são dotados de fé pública, de modo que competia à Defesa comprovar os vícios por ela alegados.

Nesse sentido: "O Delegado de Polícia é o presidente do inquérito policial e, nessa condição, detém fé pública na prática dos atos inerentes à investigação policial" (TJ-SP - HC nº 2003538-57.2020.8.26.0000, Relator(a): Alexandre Almeida, 11ª Câmara de Direito Criminal, DJe em: 02/03/2020).

E ainda que assim o fosse, eventuais vícios ocorridos em sede de inquérito policial - procedimento de caráter preliminar e meramente informativo - são considerados meras irregularidades, que não têm o condão de macular a ulterior ação penal que nele porventura se basear.

Nesse sentido: “O inquérito policial é peça meramente informativa, na qual não imperam os princípios do contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual eventuais vícios ou irregularidades ocorridos no seu curso não têm o condão de macular a ação penal” (STJ - HC 222725/MG, Relator(a): Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe em: 12/12/2016).

“Eventuais nulidades ocorridas durante a etapa das investigações, meramente informativa, não têm o condão de contaminar a ação penal posteriormente instaurada”. (STJ - AgRg no HC nº 680717/AP, Relator(a): Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe em: 25/03/2022).

Por derradeiro, também não há que se falar em nulidade por ausência do laudo pericial do local dos fatos, até porque a prova em questão não é imprescindível para que se possa aferir a proximidade entre o local da prática delituosa e o estabelecimento de ensino – a ensejar o reconhecimento da majorante do artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06 –, o que pode ser demonstrado por outros meios probatórios.

No mérito, é procedente a presente ação penal.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 05 e seguintes); boletim de ocorrência (págs. 21/25); auto de exibição e apreensão (págs. 27/28); imagem dos entorpecentes apreendidos (pág. 29); laudo de constatação (págs. 32/35); laudo de exame químico-toxicológico (págs. 418/420), que resultou positivo para a substância tetrahidrocannabinol; bem como pela contundente prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, nas oportunidades em que foi interrogado, o acusado admitiu amplamente a imputação.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda no calor dos fatos, perante a D. Autoridade Policial, relatou, em suma, que: “(...) que estava perto da CEI, uma escola infantil, quando foi abordado por policiais civis desta delegacia; que levava uma sacola, que tinha 74 (setenta e quatro) tiras de maconha e mais 20 (vinte) tubinhos plásticos também como maconha; que no seu bolso seu aparelho celular e R\$ 137,00 (cento e trinta e sete reais) em dinheiro; que, trabalha para o “BART” há cerca de dois anos, ali da Favela da 13, e dessa “biqueira” da 9, também; que indagado sobre quem entrega das drogas e faz o recolhe dos valores da venda, em quais horários, respondeu que não pode falar mais nada. Que não tem antecedente, mas vende drogas desde adolescente e nunca foi detido.”.

Em Juízo, já sob o crivo do contraditório, narrou que: “(...) Eu sou dependente químico, às vezes me pegava até vendendo meus pertences por causa de droga, e nesse momento, eu já não tinha mais o que trocar por droga. Fui na biqueira de mãos abanando e eles me pediram pra ajudar eles que eles iam me dar droga. E eu tava em abstinência, sob efeito de droga, e infelizmente eu acabei ajudando os traficantes. Eles pediram pra mim ficar lá no lugar deles e quando eles voltassem eles iam tar me dando a droga. Eu tava sob efeito de droga. Uso maconha e “spice”, “K9”. É uma droga sintética criada em laboratório que vai um resíduo de crack. Eles falaram pra mim que se aparecesse alguém era pra mim vender. Não chegou ninguém. Não conhecia os policiais. Creio eu que não (não tinham razões para incriminá-lo). Fiquei ali coisa de 30, 40 minutos. Não (não chegou ninguém pra comprar). Sim (ali é um ponto de venda de drogas). Eu ia ganhar três potinhos de “spice”, que é “K9”. Eu ia ficar até o traficante voltar. Ele (traficante) falou que ia comprar uma marmita e já voltava. Foi a primeira vez (que traficou entorpecentes). Eu trocava meus pertences por droga, mas eu não tinha dinheiro, chegou lá eles me ofereceu isso, pra mim

ajudar eles, que eu ia tar recebendo a droga que eu queria usar. (...) Quando (os estudos) era presencial eu estudava no período da noite. Quando não era, vinha mensagem no grupo da escola que tinha lição lá no site. Era qualquer horário. (...) é duas máscara (sobre a tatuagem no rosto). Significa superação. É uma sorrindo e outra chorando. Aqui é uma lágrima (sobre a outra tatuagem no rosto). Significa que eu perdi minha bisavó. Fiz na rua. Troquei por pertences meus também. Eu não tive nenhum interrogatório na delegacia. Não me apresentaram nem para o delegado. (...). O telefone celular era meu. Não (não vendia o celular para consumir drogas). O traficante já me entregou daquele jeito a sacola. Eu não sabia o que que tinha dentro, só sabia que era droga. Minha mãe tentou (submetê-lo a tratamento) muitas vezes, mas toda vez eu ia uma vez e não conseguia mais ir. Eu ia sim, assistia as aulas direitinho. Mesmo em abstinência. Que eu estava muito fissurado pela droga Vossa Excelência, fazendo as coisas sem pensar, eu só queria saber da droga e até mesmo estudar eu só estudava porque minha mãe puxava minha orelha. A biqueira era a uns 2 ou 3 quarteirões da escola. Uma viatura caracterizada invadiu a biqueira, nessa eu corri, não sabia para onde estava indo pois quando eu ia na biqueira era apenas pra comprar droga, nisso eu corri e me deparei com os policiais à paisana. (...) Só falaram pra mim pegar as droga e vender e jogar o dinheiro dentro da sacola. Eu não ia receber nenhum dinheiro, apenas drogas. Eu não li (o termo de interrogatório). Eu tava sendo já transferido para o 63. Assinei toda a papelada sem ler. Em nenhum momento ninguém se apresentou pra mim como delegado. Não conheço essa pessoa ("Bart"). Eu to arrependido de tudo. Tinha (consumido drogas). Hoje eu vejo que sim (juízo estava alterado). (...) Eu fiquei de maior e falaram que eu precisava me alistar no exército, e quando eu estava me preparando para me alistar no exército, veio essa situação (sobre o motivo de estar desempregado). Os policiais só falaram que eu estava preso e me jogou no camburão. Tinha bastante gente. Não (policiais não levaram testemunhas). (...) Eu ia vender (a droga) por 30 reais.".

E referidas confissões encontraram o necessário conforto na prova produzida em Juízo - notadamente os firmes relatos das testemunhas policiais, sem olvidar das incriminadoras circunstâncias da prisão em flagrante que realizaram -, o que comprometeu o réu sobremaneira.

Eduardo Custodio de Oliveira relatou que: "(...) Me recordo sim (da ocorrência). Ali é um ponto de tráfico já conhecido, fizemos uma breve campanha de uns 15 minutos com viatura descaracterizada de forma velada, observando a pessoa vendendo entorpecentes. Vendeu acho que pra uma ou duas pessoas e decidimos, eu e o colega de trabalho, descer da viatura e ir andando de forma à paisana para tentar abordá-lo. Eu desci na frente, 10 metros atrás desceu o colega, eu passei por ele (réu), ele estava com a sacola na mão. O colega logo atrás ficou olhando pra mim desconfiado, tentou abordá-lo, ele tentou entrar em luta corporal, aí eu voltei, como tava próximo, 5 metros aproximadamente, eu ajudei a abordar e deter ele, ele até jogou a sacola em cima de um barraco que lá tem uma comunidade próxima, ele jogou a sacola com os entorpecentes em cima de um barraco, abordamos, pegamos ele e encontramos a droga. Na verdade, nós tivemos um trabalho na delegacia que foi feita uma investigação para tentar desarticular esse local de tráfico. Prendemos alguns gerentes, subgerentes, que recolhem o dinheiro, pessoas que abastecem, e ficamos sabendo que a biqueira continuava trabalhando, e fomos lá ver e realmente estava trabalhando. Ali era em frente à escola, uma CEI infantil, ele estava em frente à escola encostado em um poste, com a sacola na mão. Sim (a escola estava em funcionamento), perfeitamente, tinha criança saindo e entrando. Foi localizado dinheiro, uma pequena porção, acho que 130 reais aproximadamente, e creio que um celular. Tinha aproximadamente 90 porções prontas para a venda, de maconha. Ele confessou, na delegacia, pra autoridade, ele confessou que era usuário e para sustentar o vício dele vendia droga, e tava trabalhando pra essas pessoas há aproximadamente dois anos. Não (não era conhecido da polícia). Como nós sabemos que ali é um ponto de tráfico, fomos ver se estava funcionando né, paramos em uma viatura descaracterizada e vimos o indivíduo vendendo para algumas pessoas, com uma

sacola na mão. Não (não detiveram os compradores), porque nós não podemos ficar muito perto porque eles desconfiam da gente, e como estávamos distante e lá é um local próximo a uma invasão, tem saída para vários lados, vielas, rios, e eles compram e vão para o lado das vielas e rios que fica mais difícil abordá-los. (...) Eu vi ele recebendo dinheiro, pegando o objeto dentro da sacola, entregando, a pessoa indo pro rio, depois a gente viu o objeto dentro da sacola que era droga. Não (não pegou consumidores), porque a gente optou por abordar ele, que estava traficando. (...) O outro (consumidor) quando viu já desceu a carreira pela viela. Tinha pessoas na frente, na escola, de van escolar. Ele não estava na viela, ele tava de frente à escola encostado em um poste, próximo a uma viela. (...) Ele tentou correr, uns 5 metros, mas não conseguiu, porque o colega vinha logo atrás. (...) Tinha somente maconha. E 130 reais. Eu e o colega (deram a voz de prisão). Abordamos ele juntos. (...) A campana durou aproximadamente uns 15 minutos.”.

Jose Roberto Pereira Bersani Junior, no mesmo sentido, aduziu: “(...) Era uma operação contra o tráfico de drogas, já tem um inquérito correndo na delegacia, nós fomos ao local, fizemos uma breve campana, identificamos quem tava na venda, decidimos por fazer a abordagem, eu e meu parceiro descemos, ele foi um pouco à frente e eu fui um pouco atrás. Meu parceiro passou por ele, ele meio que se escondeu no poste, eu fui e fiz a abordagem. Ele resistiu à abordagem, tentou dispensar a sacola que caiu em cima de um barraco de frente, conseguimos detê-lo, fomos lá, encontramos entorpecentes e o conduzimos ao distrito policial. Fizemos uma campana de mais ou menos uns 20 minutos. A abordagem foi na frente de uma escola, inclusive era hora da saída das crianças, criou um certo tumulto lá, as crianças ficaram assustadas. Era em frente a uma escola. Vimos ele fazendo vendas. Para umas 2 ou 3 pessoas. Tinha maconha, aproximadamente quase 100 papéletes, e dinheiro também, acho que uns 140 mais ou menos. As drogas tavam em uma sacola na mão dele. Quando eu realizei a abordagem, ele jogou a sacola. O dinheiro tava no bolso dele, e tinha também um pouco na sacola. As biqueiras ficam em vários locais, a gente tem no nosso inquérito também a apreensão de câmeras, que eles monitoravam a favela todinha. Lá tem várias biqueiras, porque a viela corta, então tem a biqueira da 9, a biqueira da 11 e a biqueira da 13. No momento que a gente fez a abordagem, ele estava de frente à escola, a viela passa por ela e sai cortando outras ruas. Quando nós descemos pra abordar, os indivíduos que tavam comprando já tinham saído e ele se escondeu atrás de um poste. (...) dentro da sacola tinha maconha e uma quantidade de dinheiro também. Consegui deter ele na frente da escola. Tinha testemunhas, pais de alunos, funcionários da escola, teve um monte de gente que presenciou. O flagrante por si já está bem elaborado. Eles (testemunhas) temem represálias. (...) Sim, gerou tumulto, era saída da escola. Ele (acusado) tentou se evadir. Conduzimos ao distrito policial e apresentamos a ocorrência ao delegado. Ali pertence à área do 64 DP, porém, o inquérito corre na área do 67 DP. (...) Não acompanhei o interrogatório. Informalmente, ele nos relatou que o dono da biqueira era uma pessoa de vulgo “Bart”. (...) Informalmente ele admitiu, falou que já trabalhava há mais ou menos uns 2 anos lá. Ele tirou da sacola (o que fornecia às pessoas).”.

As testemunhas arroladas pela Doute Defesa limitaram-se a atestar os bons antecedentes e a condição de usuário de entorpecentes do acusado.

Claudia Regina Pereira de Almeida Melo narrou, em suma, que: “(...) Conheço (o réu). Desde pequenininho. Ele praticamente foi criado dentro da casa da minha irmã com meu sobrinho. Sim, fiquei sabendo (da prisão do réu). (...) Fiquei sabendo que ele é usuário, que os amigos que ele conversa, tal, acho que pra se “auto afirmar” acabou usando drogas sim. Acho que foi amigo das pessoas erradas, a influência foi muito grande, então começou a usar drogas. Ele nem precisa disso, ele tem pais, a família dele é estruturada. (...) Ele sempre é muito bem-educado com todo mundo. Ele não estuda. Não trabalha. Ele estudou, se não me engano, até o segundo ano do ensino médio. Estudou até 2018. Ele mora com os pais.

Simone Cristina Ferreira, por sua vez, relatou: “(...) Conheço ele (réu) desde pequenininho, desde os 3 anos de idade. É vizinho, estudou com meu filho. Fiquei sabendo (da prisão do réu). É a primeira vez (que ficou sabendo do envolvimento do réu com o tráfico). Sim (tinha ciência de que ele era usuário de entorpecentes). Pelo comportamento dele, a gente é mãe e percebe. Acho que tem uns dois anos, por aí, ou mais. (...) Pra ser sincera, os pais dele cuidam até demais. Ele tava estudando. Acho que em 2021 ele ainda tava estudando. Ele estudou em escola particular junto com meu filho e depois foi pra escola pública. Ele estudou acho que até o 9º ano. Ele é um menino bom, só tá perdido. (...) Ele dava conselho pro meu filho não fazer o que ele fez. (...) Já ouvi dizer que ele fumava maconha. Ele perdia um pouco da vaidade, de andar bonitinho, ele se vestia melhor, e depois que ele passou a fumar ele ficou meio desleixado. Ele não trabalhava. Acho que tava no 9º ano, tava até procurando emprego em um lava-rápido e acabou acontecendo essas coisas aí.”.

Celso Pires de Carvalho, a seu turno, relatou: “(...) Conheço ele há bastante tempo, desde que era menorzinho. Ele é vizinho da minha irmã, então to sempre na minha irmã e conheço ele, a mãe dele. Não tenho nada que desabone o menino não. To sabendo (da prisão do réu). Fiquei até surpreso quando soube. Dependente e usuário eu sabia que ele era, isso aí acho que 2019 eu sei que ele era dependente. Ele é um menino bom, os pais se preocupam bastante com ele. Com certeza é má-influência de algum conhecido dele. Ele estava estudando, depois não sei se ele parou, por causa das drogas e tudo... Nunca vi ele ostentando nada.”.

Por fim, Regilda Pereira Nogueira, genitora do acusado, declarou que: “(...) Eu estava trabalhando (no momento em que ele foi preso). Isso mesmo (foi para a delegacia). Não (não conseguiu falar com a Autoridade Policial). Não (não explicaram o motivo da prisão). Só falaram pra eu comprar lanche para ele que ele estava com fome e que ele estava lá. Eu fui aonde ele tava, entregamos o lanche, e por estar passando por aquela situação, ele falou que não estava traficando, e nós nos ajoelhamos e começamos a rezar juntos, eu e ele. Não (não acompanhou o interrogatório). Não (não ficou sabendo do motivo da prisão). Não (o réu não tinha envolvimento com drogas). Ele era usuário. Do meu conhecimento tem uns 2 anos. Foi o pai dele que percebeu e me comunicou. Procuramos levar ele ao médico, ao psicólogo, ele participou, depois não quis mais, procurei um especialista na área, e ele sempre dizendo que tinha controle da situação e não era dependente. Nunca faltou nada, sempre trabalhei para dar tudo que o Pedro me pedia e precisava, vestuário, alimento, roupa, tudo eu dava. Sim (ele não estava trabalhando por causa da “fase de exército”). Sim (ele está matriculado na escola). Sim (o estudo era online). Ele não é traficante. Ele só comentou comigo que tinha ido buscar para o uso. Acredito que por más-companhias, pela idade, lugar que ele frequentou, em casa nunca teve isso, ele sempre foi estudioso, respeitador. Ele usa maconha, quando eu limpava o quarto dele, achava bituquinhas de cigarro. (...) Não teve advogado na delegacia. Ele estava estudando em uma escola na Penha, “Barão de Ramalho.”.

Como consignado, a prova produzida no contraditório é farta na demonstração da ocorrência do crime, sendo incontroversa a autoria.

Nas oportunidades em que foi inquirido, o acusado admitiu amplamente a imputação.

Em solo policial, relatou que estava nas proximidades de uma escola infantil exercendo o comércio espúrio de entorpecentes e, em dado momento, foi surpreendido por policiais, que o abordaram e o revistaram, vindo a localizar a sacola contendo as porções de entorpecentes que carregava.

Além das porções de entorpecentes localizadas – 74 “tiras” de plástico e 20 “tubinhos” contendo maconha – também havia uma quantia de dinheiro em espécie no interior da sacola. Outrossim, estava com seu telefone celular no bolso.

Acrescentou que "trabalhava" há aproximadamente dois anos naquele mesmo local para um indivíduo de alcunha "Bart".

Por fim, declarou que vende entorpecentes desde a adolescência, todavia, nunca foi detido pela polícia.

Já em Juízo – a despeito de ter procurado mitigar sua responsabilidade e justificado que era dependente químico – admitiu que traficava os entorpecentes apreendidos, sendo certo que venderia as porções de maconha em troca de algumas porções de entorpecentes, ou seja, três "saquinhos" de "spice".

Narrou que é dependente químico, estava sofrendo de abstinência e não dispunha de dinheiro para comprar drogas. Desta feita, dirigiu-se à "biqueira" e, lá chegando, os traficantes lhe propuseram que vendesse entorpecentes em troca de algumas porções de droga – três "saquinhos" de "spice".

Desta feita, aceitou a proposta e passou a traficar os entorpecentes, o que faria por um curto período de tempo – até que o traficante comprasse uma marmita e voltasse à "biqueira".

Em dado momento, deparou-se com uma viatura policial, de modo que decidiu se evadir do local. Enquanto corria, foi surpreendido por policiais à paisana, que o abordaram e apreenderam a sacola que levava consigo – a qual continha inúmeras porções de entorpecentes.

Ato contínuo, referidos policiais lhe deram voz de prisão em flagrante e o conduziram à delegacia de polícia.

Acrescentou que praticava este comércio espúrio nas proximidades de um estabelecimento escolar: "A biqueira era a uns 2 ou 3 quarteirões da escola."

Declarou que frequentava a escola à época dos fatos e assistia a todas as aulas, mesmo quando em abstinência: "Eu ia sim, assistia as aulas direitinho. Mesmo em abstinência."

Por fim, afirmou que estava desempregado à época dos fatos por força do alistamento militar: "Eu fiquei de maior e falaram que eu precisava me alistar no exército, e quando eu estava me preparando para me alistar no exército, veio essa situação (sobre o motivo de estar desempregado).".

De se ressaltar que o acusado justificou que vendia drogas como forma de conseguir sustentar seu vício, dizendo que já não dispunha de qualquer outro bem para trocar por entorpecente: "...às vezes me pegava até vendendo meus pertences por causa de droga, e nesse momento, eu já não tinha mais o que trocar por droga...". Entretanto, quando foi abordado pelos policiais estava na posse de seu aparelho celular, o que faz cair por terra essa alegação.

E essas confissões encontraram o necessário conforto na prova produzida no curso da instrução criminal, vez que os policiais inquiridos, de forma absolutamente serena e insuspeita, narraram em minúcias a diligência que realizaram – ratificando as circunstâncias do flagrante, tais como articuladas na denúncia –, que culminou na prisão do réu e na apreensão de vasta quantidade de entorpecentes em seu poder. Esclareceram que, à época dos fatos, havia um inquérito policial em trâmite para apurar informações relacionados ao tráfico de drogas naquela região – já bastante conhecida pelo comércio espúrio de entorpecentes.

Assim, dirigiram-se ao local dos fatos – uma "biqueira" localizada em frente a um estabelecimento escolar infantil – e fizeram campana por aproximadamente 15 a 20 minutos, com o objetivo de identificar a pessoa responsável pela venda de entorpecentes.

Durante a campana, viram o acusado em atividade típica de venda, ou seja, recebia dinheiro de algumas pessoas e, em contrapartida, entregava a elas algo que retirava do interior de uma sacola.

Após presenciarem a venda para aproximadamente duas ou três pessoas, decidiram pela abordagem, desembarcaram da viatura e surpreenderam o réu, que tentou se esconder atrás de um poste e arremessou a sacola por cima de um barraco.

Ato contínuo, detiveram o acusado e apreenderam a sacola arremessada.

Durante a revista pessoal, localizaram dinheiro no bolso do acusado, bem como diversas porções de maconha no interior da sacola que ele trazia consigo – cerca de 100 papelotes –, além de mais uma quantia de dinheiro em espécie e um telefone celular.

Instado, o acusado admitiu amplamente a traficância, informando que realizava esse comércio espúrio há aproximadamente dois anos, o que fazia porque era usuário de drogas. No mais, declinou que o proprietário da “biqueira” seria um indivíduo de prenome “Bart”.

Acrescentaram que o estabelecimento escolar estava em pleno funcionamento no momento da abordagem, sendo certo que havia diversas crianças transitando pelo local – que inclusive ficaram assustadas com o tumulto.

Diante de tais circunstâncias, conduziram o acusado à delegacia de polícia, oportunidade em que sua prisão em flagrante foi ratificada pela Autoridade Policial.

E os esclarecimentos prestados pelos policiais são dignos de toda credibilidade, uma vez que não existe demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoa inocente.

Como qualquer outra testemunha, os policiais prestaram o compromisso de dizer a verdade e a versão que apresentam só pode ser desprezada se existir prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que evidentemente não é o caso dos autos.

Nesse sentido: “Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas”. (TJRJ – AC – Rel Synésio de Aquino – RDTJR 7/287).

Ainda: “Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências.” (RT 417/94).

As testemunhas arroladas pela Defesa não presenciaram os fatos aqui tratados. Limitaram-se a atestar os bons antecedentes do acusado e informar que era usuário de entorpecentes, bem como que estudava à época dos fatos.

Entretanto, esses esclarecimentos não mudam o quadro probatório produzido, uma vez que, como já dito, referidas testemunhas não presenciaram a dinâmica dos fatos.

Enfim, o conjunto probatório é bastante sólido e incrimina sobremaneira o réu, ensejando uma condenação segura.

Quanto ao tóxico apreendido, desnecessário maiores digressões acerca de sua

destinação. O desiderato de mercancia é manifesto e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para dúvidas.

As inúmeras porções de maconha apreendidas, bem como a forma com que estavam embaladas – 74 invólucros de maconha, pesando 1.266 gramas, e 20 microtubos de maconha, pesando 48,7 gramas – revelam que seriam revendidas, de forma que não é o caso de desclassificação do crime denunciado para o previsto no artigo 28 da Lei Especial.

Assim não fosse, consigne-se que a situação de usuário de drogas não exclui a de traficante, uma vez que: “Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização” (TJSP - AC 9.751-3 - Rel. Gonçalves Sobrinho - RJTJSP 75/343).

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

“Tráfico de entorpecente - Grande quantidade de droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão dependência, inadmissível - Inteligência dos arts. 12 e 16 da Lei 6.368/76.” (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

Os elementos de convicção produzidos no curso da instrução criminal bem demonstraram que o réu praticava a conduta típica prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

E ao contrário do que sustenta o Dr. Defensor, a falta de testemunhas civis não elide a farta prova produzida no contraditório, mormente porque, em crimes desse jaez, as pessoas do povo temem sofrer represálias pelos narcotraficantes.

Nesse sentido: “A ausência de testemunhas civis não tem o condão de enfraquecer a prova, pois, como é cediço, em delitos dessa natureza, são os agentes públicos, na maior parte das vezes, que costumam depor contra os autores, uma vez que o cidadão comum possui o natural receio de sofrer eventual represália. Além disso, a exigência do depoimento de testemunha civil implicaria obstáculo intransponível à condenação de traficantes, com a nota de que sequer encontra respaldo legal.” (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1502332-72.2021.8.26.0536, Relator(a): Mauricio Henrique Guimarães Pereira Filho, 5ª Câmara de Direito Criminal, DJe em: 06/04/2022).

Por fim, também não socorre o acusado as alegações de que teria praticado o delito aqui tratado sob o efeito de entorpecentes, nos termos do que estabelece o artigo 28, II, do Código Penal.

A majorante denunciada fica reconhecida.

Com efeito, restou incontroverso – tanto pelos depoimentos dos policiais quanto pelas declarações apresentadas pelo acusado em Juízo e em solo policial – que ele praticava o comércio espúrio de entorpecentes nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo o que basta para a incidência da causa de aumento de pena em questão.

Nesse sentido: “Quando a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento de ensino, dentre outros locais expressamente elencados no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, resulta adequada a aplicação da causa especial de aumento de pena, independentemente da comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades.” (STJ - AgRg no REsp nº 1.845.613/SC, Relator(a): Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe em: 12/02/2020).

Demonstrada a ocorrência do crime, e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

Ao que consta, o acusado era tecnicamente primário à época dos fatos.

Logo, atendendo aos critérios norteadores do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Pena-base fixada no mínimo legal não comporta redução por força de circunstância atenuante (Súmula 231 do STJ).

Incidir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j' do Código Penal, já que o delito foi praticado durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia da Covid-19 (Decreto Estadual nº 64.879 e Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020).

Cumprido ressaltar que a lei não exige nexo de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime praticado pelo agente. Basta, para o reconhecimento da agravante em questão, que o delito seja executado durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, reconhecida por meio dos decretos supramencionados, o que indica insensibilidade moral dos agentes e ausência de fraternidade e solidariedade social.

Nesse sentido: "(...) Agravante do crime perpetrado em estado de calamidade pública - Reconhecimento - Necessidade - Inteligência do artigo 61, II, 'J', do Código Penal. (...) O réu praticou o delito em estado de calamidade pública, no lapso estabelecido no Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março do ano corrente, não se importando com o estado de vulnerabilidade a que submetida a população em geral. É o que basta a subsumir sua conduta ao insculpido no artigo 61, II, 'j', do Código Penal. (TJ-SP - APR: 15101948220208260228 SP 1510194-82.2020.8.26.0228, Relator: Mauricio Valala, Data de Julgamento: 05/11/2020, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/11/2020).

O texto legal estabelece que a pena é agravada se o agente comete o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, nada mencionando sobre a necessidade de nexo de causalidade entre o crime e as situações mencionadas.

Inobstante, referida agravante fica compensada com a atenuante da confissão espontânea, bem como com a atenuante da menoridade relativa - réu contava com menos de 21 anos à época dos fatos.

Por força da majorante reconhecida, aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, calculada a unidade no mínimo legal.

E não estão presentes os requisitos para a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, conforme se verifica do quadro probatório produzido, o acusado promovia o tráfico ilícito de entorpecentes há pelo menos dois anos, sendo certo que tinha envolvimento com traficantes de alto escalão. Aliás, é nesse sentido o relato prestado pelo réu em solo policial: "(...) que, trabalha para o 'BART' há cerca de dois anos, ali da Favela da 13, e dessa 'biqueira' da 9, também; que indagado sobre quem entrega das drogas e faz o recolhimento dos valores da venda, em em quais horários, respondeu que não pode falar mais nada.". (pág. 11).

E ao que tudo indica, não exerce qualquer atividade lícita - até porque não produziu qualquer prova a respeito. Nas oportunidades em que foi ouvido, afirmou que estava desempregado, não sendo desarrazoado presumir que faz da traficância seu meio de vida - até porque, como dito, declarou que trabalhava com o tráfico de drogas há dois anos.

Não bastasse, foi surpreendido em poder de vultosa quantidade de maconha - mais de um quilo da droga -, separada em inúmeras porções, todas prontas para consumo.

Ora, não se confia tamanha quantidade de drogas a quem é incipiente no comércio ilícito em questão.

Também considerando a grande quantidade de droga apreendida, capaz de abastecer um bairro inteiro, atingindo um número considerável de usuários e causando danos irreversíveis à saúde pública, a demandar maior censura, inaplicável o redutor de pena em questão.

Nesse sentido: "(...) não é suficiente o mero preenchimento objetivo dos requisitos preconizados no aludido dispositivo legal primariedade, bons antecedentes e não dedicação às atividades criminosas ou participação em organização criminosa para que seja declarado o direito à diminuição da pena. Há, também, necessidade da fiel observância do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, que estabelece que a natureza e a quantidade da substância ou produto entorpecente devem ser consideradas, com preponderância, sobre o que dispõe o artigo 59, do Código Penal, permitindo, por isso mesmo e por antítese ao primeiro dispositivo (artigo 42), até mesmo a negativa da redução. Assim, além das circunstâncias pessoais favoráveis (artigo 59, do CP) e por oposição à regra do artigo 42, da Lei de Drogas, não pode ser excessiva, como na hipótese dos autos, a quantidade de entorpecente apreendida, sob pena de inaplicabilidade do redutor em questão" (14ª Câmara Criminal- Apelação Criminal nº 0086767-42.2010.8.26.0050; Des. Rel. Fernando Torres Garcia; j. 31/05/2012).

E ainda: "PENA - Fixação - Tráfico ilícito de entorpecentes - Aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei Federal n. 11.343/06 - Inviabilidade - Agente surpreendido quando trazia consigo 59 porções de maconha e 11 de cocaína - Quantidade de drogas apreendidas indicadora de que o réu faz do tráfico seu meio de vida, ou seja, de que se dedica à atividade criminosa, não sendo, portanto, merecedor da redução da reprimenda - Recurso da defesa improvido, sendo dado parcial provimento ao ministerial para elevar as penas impostas" (Apelação Criminal n. 990.09.081797-6 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery - 01.10.09 - V.U. - Voto n. 15796).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra PEDRO MIGUEL PEREIRA NOGUEIRA, R.G. nº 54.463.462, e o condeno ao cumprimento de cinco anos e dez meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a quinhentos e oitenta e três dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, c. c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO, tendo em vista o que dispõe a Lei nº 11.464/07, que alterou a redação original do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90.

Tendo em vista a gravidade do crime, aqui tratado, considerado hediondo, o acusado NÃO poderá recorrer em liberdade, deverá ser recomendado na prisão em que se encontra e, igualmente, não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, que não tem aplicação ao crime tratado na presente ação penal, que tem regras especiais e que são aplicadas em detrimento das gerais. Por se tratar de crime hediondo, que compromete a saúde pública, a medida não se mostra socialmente recomendável.

Nesse sentido: "APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença absolutória - Recurso do Ministério Público postulando a condenação do acusado, nos termos da inicial acusatória, pelo crime de tráfico de drogas, bem como a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, o reconhecimento da agravante da reincidência e a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena - Cabimento - Materialidade e autoria comprovadas - 45 (quarenta e cinco) microtubos plásticos encontrados no exato local em que o réu se abaixou, próximo de sua carteira que também foi dispensado pelo Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar o decreto condenatório - Pena-base fixada acima do mínimo legal, tendo em vista os péssimos antecedentes do réu - Aplicação da agravante da reincidência - Não aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Substituição por restritivas de direitos - Descabimento - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime - RECURSO PROVIDO" (TJSP; Apelação 0001725-63.2017.8.26.0540; Relator(a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019).

"ENTORPECENTE. Tráfico. Desclassificação em primeiro grau para o delito de posse de tóxico para uso pessoal. Recurso ministerial buscando a condenação pelo crime de tráfico. Circunstâncias da abordagem e quantidade de entorpecente apreendido indicando destinação comercial, segundo os critérios do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06. Condenação por tráfico que se impõe. Dosimetria. Básicas que partem dos mínimos legais, sendo acrescidas de um quinto, na segunda fase, pela dupla reincidência, a qual, aliás, impede a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/0. Regime fechado necessário, sendo incogitável a substituição das penas corporais por restritivas de direitos. Apelo ministerial provido, com determinação" (TJSP; Apelação 0004107-35.2017.8.26.0635; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019).

Pelos fundamentos acima expostos, bem como por tudo quanto produzido no contraditório, presentes os requisitos legais, MANTENHO a prisão preventiva anteriormente decretada, nos termos do que estabelece o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ademais, a medida se mostra necessária, inclusive, para assegurar o cumprimento da pena aplicada. Por esses argumentos, fica prejudicado o pedido de liberdade provisória formulado pela Douta Defesa (págs. 468/474).

É certo que o réu está preso desde 04 de outubro passado, mas não é o caso de regime mais brando para início de cumprimento da pena (artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal), porque eventual progressão é matéria que deve ser decidida pelo Juízo das Execuções Criminais, como determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c" - detração penal, da Lei nº 7.210/84, com observância do que dispõe o artigo 112 e parágrafo 1º, da mesma lei.

Nos termos do artigo 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06 e do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, DETERMINO a perda em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, ou seja, R\$ 137,00 (cento e trinta e sete reais) relacionada no auto de exibição e apreensão (págs. 15/16), uma vez que oriunda do comércio espúrio em questão.

Condene o acusado ao pagamento das custas do processo, nos termos do que estabelece o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Com relação ao pleito de restituição do celular apreendido (págs. 15/16), concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o acusado apresente provas da titularidade e da aquisição lícita do bem, nos termos do disposto no artigo 60, § 5º, da Lei nº

11.343/06. No silêncio, aguarde-se o decurso do prazo previsto no artigo 123 do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de abril de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA